



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 96/11

לפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

1. בצלאל שמחוביץ ת.ז. 20853
2. אסתר שמחוביץ ת.ז. 91579
ע"י ב"כ עו"ד יהושע ננר

התובעים:

- נ ג ד -

1. רוברט הנוך ת.ז. 332336957
2. מונה הנוך ת.ז. 332289081
ע"י ב"כ עו"ד זאב סמואל ועו"ד מיכאל אוסיון

הנתבעים:

פ ס ק – ד י נ

עניינו של פסק דין זה בגישה לגג הבית המשותף, שימוש ייחודי בחלקו, ודינה של צנרת בחזית הבית המשותף.

א. העובדות

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30010 חלקה 80, והממוקם ברחוב הצפירה 1 בירושלים (להלן: "הבית המשותף").
2. התובעים אווזים יחד ב- 2/5 מזכויות הבעלות בדירה הידועה כתת חלקה 1 המצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף. דירה זו משמשת בפועל כמסעדה, המושכרת לצד שלישי. שלושת הבעלים הנוספים (אשר לכל אחד מהם 1/5 מזכויות הבעלות) הם אחיהם ואחיותיהם של התובעים. לתת חלקה 1 צמוד בית שימוש וחלק מהחצר (להלן: "המסעדה").
3. התובעת 2 היא גם הבעלים והמחזיקה בדירה הידועה כתת חלקה 5, הממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף (להלן: "דירת התובעת"). התובע 1 איננו מתגורר בבית המשותף.
4. הנתבעים הם בעליה של תת חלקה 8, הממוקמת בקומה השנייה (קומת הגג) של הבית המשותף. שטחה של דירה זו, על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים, הוא 75.8 מ"ר, ולה צמוד גג בשטח של 95 מ"ר (להלן: "דירת הנתבעים").
5. לבית המשותף קיים תקנון מוסכם, אשר עוסק בעיקר בקביעת הוראות בנוגע להצמדת חלקים מן הרכוש המשותף לדירות שונות, וקביעת החלק ברכוש משותף של כל דירה ודירה. כאמור בסעיף 4 לתקנון המוסכם, הוראותיו אינן באות לגרוע מהאמור בתקנון המצוי.
6. בכתב התביעה המתוקן (על נסיבות הגשתו יפורט בהמשך), מבקשים התובעים להורות לנתבעים לסלק את ידם מכל חלקי הרכוש המשותף ולפרק או להרוס כל בנייה שבוצעה שלא כדין ברכוש המשותף, וכן להורות לנתבעים לאפשר לתובעים ולכל יתר בעלי הדירות גישה חופשית לגג הבניין. עוד מבוקש להורות לנתבעים לפרק את צינור הביוב והצנרת הנוספת שהותקנו על ידם לאורך הקיר החיצוני בחזית הבניין,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ולחשיב את המצב לקדמותו כפי שהיה עובר לכניסתם לדירה. בנוסף מבקשים התובעים להורות לנתבעים לאפשר לכל בעלי היחידות בבניין שימוש חופשי ויומיומי בגג הבניין.

7. ביום 10.1.12 ביקר במקום, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, עמיתי המפקח אורן סילברמן, אשר דן בהליך בראשיתו. ביום 3.9.13 ערכתי גם אני ביקור במקום.

הליכים קודמים

8. בין הצדדים, או קודמיהם, התנהלו הליכים משפטיים שונים, אשר בשל חשיבותם לעניינינו יוזכרו להלן בתמצית.

9. ההליך הראשון התנהל בין חמשת בעלי המסעדה, ובכללם התובעים (להלן: **"בעלי המסעדה"**), אשר הגישו תביעה כנגד יתר בעלי דירות בבית המשותף, ביניהם הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים, שפרה ויוסף גיל (להלן: **"גיל"**). הליך זה התקיים בבית משפט השלום בפני כב' השופט רפי שטראוס ז"ל (ת.א 12268/02- להלן: **"ההליך הראשון"**). מוקד המחלוקת בהליך הראשון היה בשימוש ברכוש המשותף. התובעים קבלו על השתלטות בעלי הדירות על חלקים ברכוש המשותף ומניעת השימוש באותם חלקים מיתר בעלי הדירות. בעלי המסעדה עתרו לסילוק ידם של בעלי הדירות מהרכוש המשותף עליו השתלטו לטענתם, וכן לתשלום פיצוי או דמי שימוש ראויים בעבור התקופה בה נשלל מהתובעים השימוש באותם חלקים. התובעים הגיעו בהמשך ההליך להסכמה עם מרבית הנתבעים, ובכלל זה גיל, ואלו נמחקו ממנו כנתבעים, כך שבסופו של דבר לא עסק פסק הדין בעניינם של אלו. עם זאת, ביקר בית המשפט בפסק דינו את התנהלות התובעים וציין כי **"לא אוכל שלא לציין התרשמותי (שהתובע 1 אישר(ה) למעשה) שתביעה זו הוגשה לצורך מטרה שאין בינה לבין הסעדים המתבקשים ולא כלום. אין לתובעים כל עניין בגינה או ביתר חלקי הרכוש המשותף. אין הם מתגוררים בבית ומזה שנים לא היה להם סיג ושיח עם דייריו. חפצם הוא להוסיף שטח כלשהו לצורך מחסן לבית הקפה ותו לא"** (ראה בפסקה 10 לפסק הדין).

10. הליך נוסף, לו נודעת חשיבות רבה יותר לעניינינו, התנהל בין גיל לבעלי המסעדה בבית משפט השלום בירושלים, לפני כב' השופט ד. מינץ (ת.א 14565/06 – להלן: **"ההליך הקודם"**). בהליך הקודם תבעו בעלי המסעדה את גיל, בטענה כי הם בנו חדר נוסף על הגג, וגרם מדרגות המוביל אליו, וכל זאת ללא קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות, ובהם בעלי המסעדה, ומבלי שניתן להם היתר בנייה לכך. נטען שם, כי כתוצאה מבנייה זו נמנעה מבעלי המסעדה האפשרות לעלות לגג הבית המשותף. עוד נטען באותו הליך כי צנרת האינסטלציה שהותקנה לניקוז שפכי תוספת הבנייה (להלן: **"הצנרת החיצונית"**) לא הותקנה כראוי וכתוצאה מכך זרמו מי השפכים אל מחוץ לצנרת החיצונית, על קירות וחצר הבית המשותף. באותה תביעה ביקשו בעלי המסעדה כי בית המשפט יורה על סילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף, למעט גרם המדרגות (בו ביקשו התובעים להשתמש לצורך עלייתם לגג), השבת המצב לקדמותו, וסילוק הצנרת החיצונית שהתקינו (או לחלופין – תיקונה).

11. בית משפט השלום דחה את טענת התובעים בכל הנוגע לבניית החדר הנוסף, שכן מצא כי גיל אחז בהסכמת בעלי הדירות כדין לבנייתו. עוד נדחתה טענת בעלי המסעדה בדבר זכותם לעלות אל גג הבית המשותף באמצעות גרם המדרגות שבנו גיל. נקבע, כי מדובר בגרם מדרגות אשר נבנה בשטח שהוצמד



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לדירת גיל ולפיכך אין לבעלי המסעדה כל זכות בו. עוד נקבע, כי בעלי המסעדה עצמם הם שסיכלו מציאת פתרון חלופי לגישה לגג, שכן בעת שביקשו גיל להשיב את מצב לקדמותו ולפתוח פתח מחדר המדרגות לגג, הם פנו לבית המשפט במסגרת בש"א 4571/06 וביקשו למנוע מהם לעשות כן.

12. ביחס לצנרת החיצונית נקבע, כי טענת התובעים באשר לעצם התקנתה במקום בו הותקנה כחלק מעבודות הבנייה התיישנה, והטענות בדבר זרימת מי שפכים ממנה על קירות הבית ולחצר המשותפת לא הוכחו כלל.

13. בשולי פסק דינו הצטרף כב' השופט מינץ להערת כב' השופט שטראוס ז"ל, באומרו כי "אני שותף לדברים אלו של בית המשפט אז, ותביעה זו אינה אלא פן אחר של ניסיון התובעים להשיג יותר מאשר מגיע להם על פי הסכמותיהם המפורשות שניתנו בעבר" (ראה בעמ' 12 לפסק דינו של כב' השופט מינץ, פסקה 22 סיפה).

14. ערעור אשר הוגש על פסק דין זה (ע"א 3016/09, לפני כב' השופטים צ. זילברטל, ג. כנפי-שטייניץ, ר. יעקובי-נדחה).

בקשה לסילוק על הסף מחמת מעשה בית דין

15. נוכח פסק דינו של כב' השופט מינץ (אשר אושר כאמור בערכאת הערעור) כמתואר לעיל, עתרו הנתבעים בבקשה לסילוק התביעה דן על הסף. הנתבעים, מי שקנו את דירתם מגיל ומהווים למעשה חליפיהם, טענו כי מדובר בתביעה "ממוחזרת" אשר עילותיה נדונו והוכרעו כבר בהליך הקודם ולפיכך יש לדחותה על הסף. המפקח אורן סילברמן בחן טענה זו, קיבל את מרביתה, וקבע, בין היתר, כדלהלן:

"... לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה לסילוק התובענה על הסף בחלקה ומורה על דחיית התביעה, מחמת מעשה בית-דין, שעניינה בבנייה על גג הבית לרבות החדר הנוסף על הגג ובתפיסת החזקה הייחודית על שטח הגג לשם כך, כמפורט בסעיף 17 לכתב התביעה.

למען הסר ספק, בכל הקשור לטענה בדבר העדר גישה לגג הבית והעבודות שבוצעו על ידי הנתבעים בהקשר זה ובכל הקשור לצנרת הביוב והצנרת הנוספת על קירות הבית, אינני מוצא מקום לדחות את התובענה בשלב זה ויש לקיים דיון לגביה.

הנתבעים יהיו רשאים לשוב ולהעלות טענותם בדבר מעשה בי דין במסגרת סיכומיהם לאחר גמר מסכת הראיות...".

(ראה החלטה בבקשה לסילוק על הסף (תיק בקשה 193/10) מיום 15.12.11).

16. כעולה מן ההחלטה, המפקח סילברמן לא דחה את טענות הנתבעים כי גם על יתר חלקי התביעה (היינו אלו אשר לא נדחו על הסף בהחלטתו) חל מעשה בית דין, אלא שהמפקח סבר כי על מנת להכריע בטענות אלו יש להידרש לשמיעת המסכת הראייתית בשלמותה. זאת, בין היתר, על מנת לקבוע האם מדובר בבנייה חדשה אשר לא נדונה ולא יכולה הייתה לדון בהליך הקודם, או שמא אכן מדובר בסוגיות אשר הוכרעו זה מכבר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

17. לאחר מתן ההחלטה בבקשה לסילוק על הסף, עתרו התובעים לתיקון כתב תביעתם והוספת סעד נוסף בנוגע להשתלטות על הגג המהווה רכוש משותף, באופן בו מבוקש כי המפקח יורה לנתבעים לאפשר לכל בעלי היחידות בבניין שימוש חופשי ויומיומי בגג הבניין. הבקשה התקבלה ביום 28.2.12, וכתב תביעה מתוקן הוגש ביום 4.3.12.

הסעדים הדרושים להכרעה במסגרת הליך זה

18. מכל האמור לעיל, עולה כי במסגרת ההליך דגן נותר להכריע בסעדים הנוגעים לגישה לגג, לצנרת ומערכת הביוב, ולשימוש הייחודי בגג הבית המשותף (שאיננו החדר הנוסף שבנו הנתבעים על הגג). יתר הסעדים, נדחו, כאמור לעיל, מחמת מעשה בית דין.

19. הסעדים הרלוונטיים, אפוא, הנם אלו:

- **להורות לנתבעים לאפשר לתובעים ולכל יתר בעלי הדירות גישה חופשית אל גג הבית המשותף (סעיף 18 לכתב התביעה).**

- **להורות לנתבעים לפרק את צינור הביוב והצנרת הנוספת שהותקנו על ידם לאורך הקיר החיצוני ולהשיב את המצב לקדמותו (סעיף 19 לכתב התביעה).**

- **סילוק ידם של הנתבעים מגג הבית המשותף שלגביו לא ניתנה הכרעה בהליך הקודם- (חלק מסעיף 17 וסעיף 19 א לכתב התביעה).**

ב. עיקרי טענות הצדדים

תמצית טענות התובעים

20. לטענת התובעים, לאחר שרכשו הנתבעים את דירתם (בהתאם להסכם רכישה מיום 31.10.10) הם החלו באופן מיידי בביצוע שיפוצים ועבודות שונות, אשר שינו את מצב הרכוש המשותף וכפועל יוצא את אפשרויות השימוש והגישה המוקנות לתובעים ברכוש המשותף.

21. התובעים טוענים כי כתוצאה מעבודות אלו נמנעה מהם אפשרות הגישה לגג הבית המשותף באמצעות כניסה דרך גרם המדרגות.

22. התובעים טוענים עוד כי הנתבעים מסרבים להתקין מתקן או מדרגות בחדר המדרגות, אשר יאפשרו את גישת התובעים לגג. נטען, כי הנתבעים מתעקשים על התקנת סולם, בידעם כי התובעים אינם מסוגלים לעשות בו כל שימוש (נוכח מצבם הבריאותי הנטען).

23. נטען, כי לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם, התקינו הנתבעים צנרת בחזית הבית המשותף, וזאת, לשיטת התובעים, שלא כדין, וללא הסכמת כל בעלי הדירות. נטען כי הצינור שהותקן יצר מפגע תברואתי ממשי, וגרם להצפות חוזרות ונשנות.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

24. עוד טוענים התובעים כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי בחלק מגג הבית המשותף, ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בכלל והסכמת התובעים בפרט. נטען, כי הנתבעים ריצפו את חלקו של הגג ואף הציבו בו מתקנים פרטיים שלהם (אין מדובר על החדר הנוסף בגג שהוספתו לדירתם אושרה בהליך הקודם, אלא על שטח אחר של הגג המשותף).

תמצית טענות הנתבעים

25. הנתבעים מציינים כי כל טענות הנתבעים בתביעה זו נועדו להשיג מטרה אחרת- שאינה ממין הליך זה- והיא לקבל שטח ליצירת מחסן על הגג לצרכי המסעדה. לטענת הנתבעים, גם הגשת תביעה זו מהווה ניסיון סחיטה שבא להכריח אותם לוותר על חלקם בגינה המשותפת תמורת "ויתור" התובעים על השימוש בגג.

26. לטענת הנתבעים, טענות התובעים בנוגע לגרם המדרגות מתייחסות לאותו גרם מדרגות אשר נדון בהליך הקודם, ונקבע בו כי הוא איננו מהווה רכוש משותף ואין לתובעים כל זכות בו. לפיכך, קיים השתק עילה או לפחות השתק פלוגתא, ביחס למניעת אפשרות הגישה לגג הבית המשותף.

27. הנתבעים מדגישים כי הציעו להתקין סולם מתקפל לשם גישה לגג המשותף, אולם התובעים סיכלו הצעה זו.

28. באשר לצנרת טוענים הנתבעים כי מדובר בצנרת חדשה אשר החליפה שלושה צינורות ישנים. הנתבעים מכחישים כי יש בצנרת משום פגיעה בחזית וחזות הבית המשותף. לשיטתם, הצנרת החדשה דווקא הטיבה את מראה חזית הבניין ביחס למצב ששרר קודם לכן. הנתבעים מכחישים כי פער חור לשם התקנת הצנרת.

29. נטען עוד, כי הנתבעים לא ביססו כלל את טענתם באשר לגרימת הצפות חוזרות ונשנות, לכאורה עקב פגמים בצנרת, ולא הובאה כל הוכחה או חוות דעת לתמיכה בטענה זו.

30. מכל מקום, טוענים הנתבעים, גם את הסעדים המבוקשים בעניין הצנרת יש לדחות מחמת קיומו של השתק עילה או לחלופין פלוגתא, שכן בהליך הקודם כבר נקבעו קביעות עובדתיות ביחס לצנרת זו.

31. הנתבעים חולקים על הטענה בדבר שימוש ייחודי בגג הבית המשותף. לטענתם, הרהיטים המונחים שם הם ארעיים ואינם קבועים, ואין כל מניעה כי יתר בעלי הדירות יעשו בגג שימוש דומה. לטענתם, הריצוף על פני חלק מהגג המשותף היה קיים שם עוד קודם לכניסת הנתבעים לדירתם והם לא ביצעו בו כל שינוי.

32. מכל מקום נטען כי התובע כלל אינו מתגורר בבית המשותף כך שטענתו לצורך בשימוש בגג בנסיבות אלו היא קנטרנית. באשר לתובעת, טוענים הנתבעים, הרי שהיא סובלת מנכות, כך שלא סביר כי תבקש לעלות 60 מדרגות על מנת לעשות שימוש בגג, שעה שברשותה גינה רחבה הצמודה לדירתה שלה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. דיון והכרעה

השאלות הטעונות הכרעה

33. שלוש שאלות, אם כן, נותרו להכרעה במסגרת הליך זה. **האחת**, האם הבנייה שביצעו הנתבעים מנעה את אפשרות הכניסה לגג, והאם על הנתבעים החובה לאפשר גישה חופשית לגג, וכיצד. **השנייה**, האם הנתבעים התקינו צינור ביוב וצנרת חדשה בחזית הבית המשותף, ושלא כדין. ככל ששאלה זו תיענה בחיוב- האם יש להורות על פירוקם והשבת המצב לקדמותו. **השלישית**, האם הנתבעים עושים שימוש ייחודי בחלק מהגג המשותף שלא כדין, ואם כן- האם יש להורות על סילוק ידם משם.

34. עוד קודם שנדון בשאלות אלו, יש להידרש לטענתם המקדמית של הנתבעים, אשר חזרה ועלתה גם בסיכומיהם, והיא כי **חל השתק** (בין אם מסוג עילה ובין אם מסוג פלוגתא), המצדיק את סילוק התביעה על הסף, לפחות בכל הנוגע לסעדים המבוקשים בגין דרך הגישה לגג והתקנת הצנרת.

המסגרת המשפטית – מעשה בית דין

35. העיקרון בדבר מעשה בית דין מורכב משני כללים עיקריים, הידועים כיום כ-**"השתק עילה"** ו- **"השתק פלוגתא"**. היטיב לבאר זאת בשעתו הנשיא ש' אגרנט בע"א 246/66 **קלוז'נר נ' שמעוני**, פ"ד כב(2) 561, 583-584 (1968):

"הכלל האחד הוא: מקום שתביעה נדונה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. במקרה כזה, אם במשפט הראשון זכה התובע בדיון, כי אז אומרים שעילת תביעתו שם "נבלעה" (MERGED) בפסק-הדין, אשר הכיר בזכותו ובא במקום העילה, שאיננה עוד, בחינת TRANSIT IN REM JUDICATAM; וכן, אם במשפט הראשון זכה הנתבע בדיון, אזי אומרים שקם מחסום (BAR) המשתיק את התובע מלחזור על תביעה שניה המבוססת על אותה עילה, בחינת היותה חסומה או מושתקת PER REM JUDICATAM. עד כאן הכלל הראשון ורגילים לכנותו בשם "ענין שנדון" (EADAM RES) ולאחרונה בשם "השתק ישיר" (DIRECT CAUSE OF ACTION) ואף "השתק העילה" (ESTOPPEL). הכלל העיקרי האחר הוא: אם במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסויימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי הדיון וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי-הזהות בין העילות של שתי התביעות. העיקר הזה ידוע בשם הכלל של EADAM QUAESTIO ויש המכנים אותו בשם "השתק עקיף" (COLLATERAL ESTOPPEL) או "השתק הפלוגתא". (ISSUE ESTOPPEL)".

36. אחד התנאים לביסוס השתק פלוגתא מציב דרישה לפיה:

"ההתדיינות הסתיימה בהכרעה, מפורשת או מכללא, של בית המשפט באותה פלוגתא בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא של חוסר הוכחה"
(ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך האזרחי 141, 190-191 (1991)).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

37. על הרציונל העומד בבסיס כללים אלו, נאמרו בע"א 4078/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל ([פורסם בנבו], 8.9.2005) הדברים הבאים :

"בבסיס הכלל של מעשה בית דין ניצב רעיון סופיות הדיון שהצדקה לו נעוצה בשני שיקולים עיקריים. האחד מגלם את האינטרס הציבורי בסופיות הדיון המשפטי. האינטרס הציבורי אינו אלא מכנה משותף לשיקולים שונים: הקלת העומס המוטל על בית המשפט, הקטנת עלויות ההתדיינות של המערכת השיפוטית ושמירה על יוקרתה של המערכת השיפוטית העלולה להישחק באם יתאפשר לבעל דין לחזור פעם אחר פעם לאולמות בתי המשפט עד אשר יצליח להשיג את מבוקשו. השיקול השני, עניינו בבעלי הדיון עצמם. לבעל דין אינטרס מובהק שלא יוטרד בשנית בשל עילה או פלוגתא בה התדיין בעבר בפני בית המשפט. כך, לא יצטרך בעל הדיון לשמור על ראיותיו ולא לחשוש כי בעתיד נכון לו מאבק משפטי נוסף, המצריך השקעת משאבים רבים, בעניין זהה לזה שכבר הוכרע בעבר" (שם, פסקה 7 לפסק דינה של השופטת ע' ארבל).

מן הכלל אל הפרט

38. האם חל בעניינינו מעשה בית דין?

39. נפתח בבחינת הסוגיה הנוגעת למתן אפשרות הגישה לגג.

40. בהליך הקודם, כאמור, נפסק כי גיל בנו גרם מדרגות בשטח שהוצמד לדירתם, ולפיכך אין לבעלי המסעדה כל זכות בו. כך גם נקבע כי בעלי המסעדה הם שסיכלו מציאת פתרון חלופי לגישה לגג.

41. התובעים טענו בהליך זה, כי מדובר בבנייה חדשה של הנתבעים, היינו כי למעשה הנתבעים הם שמנעו את הגישה לגג, ושינו את דרכי הגישה אליו ("כתוצאה מהעבודות הנ"ל (שביצעו כביכול הנתבעים - י.ע.ש) נמנע לחלוטין מהתובעים ויתר בעלי היחידות בבניין להגיע לגג הבניין ואו להשתמש בו" - ראה פסקה 9 לכתב התביעה המתוקן).

42. ב-"סיכומי התובעים בטענות מקדמיות" מיום 12.12.11 - סעיף ז3-ט, מבארים התובעים טענתם. לפי גישה זו, אמנם בזמנם של גיל, היינו בהתאם למצב העובדתי אשר שרר בזמן הדיון בהליך הקודם, אפשרות הגישה לגג הייתה מתוך דירת גיל ולא ישירות מחדר המדרגות. אלא, שלטענתם, מדובר היה במצב בו מיד לאחר הכניסה לדירתם ניתן היה לפנות שמאלה ולעלות במדרגות לגג. הנתבעים, כך על פי הטענה, סגרו את דלת אותה כניסה לדירת גיל, יצרו כניסה חדשה לדירתם מחדר המדרגות והזיזו את המדרגות למיקום אחר בדירה. בכך- לטענת התובעים- שונו דרכי הגישה לגג ולפיכך לא חל בנדון כלל מעשה בית דין.

האמנם?

43. כאן המקום לחזור על קביעותיו של בית המשפט בהליך הקודם בכל הנוגע למדרגות המובילות אל הגג, והשימוש שנעשה בהם :



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

" עולה אפוא, מתוך מכלול העדויות שנשמעו בבית המשפט, כי הגישה לגג עובר לבניית התוספת על ידי הנתבעת הייתה דרך חור בקיר או בגג חדר המדרגות בקומת דירת הנתבעת באמצעות סולם שהיה מותקן על הקיר במקום. זאת בנוסף ליציאה נוספת שהייתה לגג מתוך דירת הנתבעת. לכן אין ממש בטענת ב"כ התובעים בסיכומיו כי המדרגות שבדירת הנתבעת הינן האמצעי הסביר והבטיחותי היחיד שיכול לשרת את הדיירים לצורך הגישה אל הגג המשותף. הנתבעת לא התחייבה מעולם לבנות גרם מדרגות אל הגג, ואין ספק כי המדרגות נועדו מלכתחילה לשמש לעלייה לחדר הנוסף שבנתה הנתבעת מעל לתוספת והם לא נועדו לשמש לעליית כלל דיירי הבניין לגג. די ברור גם כי לא הייתה כל תקופה בה גרם המדרגות הועמד לשימוש כלל הדיירים בבניין. טענת התובעים כי גרם המדרגות שימש את כלל דיירי הבניין לעלות אל הגג אינה עולה בקנה אחד עם הודאתם כי מאז תחילת שנות התשעים ועד לשנת 2006 הם מיעטו לבקר במקום ולא ידעו כלל על הבנייה שביצעה הנתבעת... (פיסקה 17 לפסק הדין בהליך הקודם).

44. לפיכך, נדחתה התביעה, ובכלל זה גם דרישת התובעים להותיר את גרם המדרגות על מנת לאפשר להם לעשות בו שימוש לצורך העלייה לגג.

45. הנה כי כן, הטענות העובדתיות של התובעים בהליך דנן **סותרות מניה וביה את הקביעות העובדתיות בהליך הקודם** - הן ביחס לגרם המדרגות בדירת הנתבעים ויעודו, והן ביחס לדרכי הגישה לגג בעבר.

46. העובדה כי הנתבעים שינו את מיקומן של המדרגות הפנימיות **בתוך דירתם**, ואף בנו מדרגות "לולייניות" במקום "ישרות", אין בה כדי להוות כל שינוי נסיבות רלוונטי. עיקר הדברים הוא בממצא של בית המשפט בהליך הקודם לפיו טרם בניית תוספת הבניה בדירת הנתבעים והצמדת חלק מהגג לדירתם, **לא הייתה דרך גישה לגג באמצעות מדרגות כלל וכי גיל אף מעולם לא התחייבו לאפשר גישה לגג מתוך דירתם**.

47. **לשון אחר** - אינני סבורה כי יש בשינוי בכדי להוות "בנייה חדשה", אשר חוסמת את טענת הנתבעים לפיה חל כלל מעשה בית דין. החשיבות המרכזית בפסק הדין בהליך הקודם היא בממצא העובדתי לפיו המדרגות לגג מצויות **בתוך דירת הנתבעים**, ואין לתובעים כל זכות בהן. נקבע, כי מעולם לא הייתה דרך גישה לגג באמצעות מדרגות כי אם על ידי סולם מחדר המדרגות. המקום בו הוצב אותו סולם, כך נקבע, כלל לא הוצמד לדירת הנתבעים. - "... בכל מקרה לא יעלה על הדעת לתת לתובעים מעבר חופשי דרך דירתם של הנתבעים, מקום בו במשך למעלה מחמש עשרה שנה לא היה לתובעים מעבר שכזה. מה גם, שהוכח כאמור, שהתובעים "סברו וקבלו" עליהם מצב כזה בשתיקתם רבת השנים (ראה בפסקה 15 לפסק הדין בהליך הקודם)".

48. לפיכך, **הרי שיש בקביעות אלו, לכל הפחות, השתק מסוג פלוגתא**, המונע מהתובעים לחזור ולהעלות לדיון את הטענה כי הייתה קיימת גישה לגג באמצעות מדרגות קודם לבניה שביצעו הנתבעים (שכן כבר נפסק שלא כך הדבר), ולפיכך שיש לאפשר להם גישה לגג באמצעות מדרגות (כביכול, כפי שהיה נהוג בעבר).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

49. ביחס לסעד הנוגע לחיוב הנתבעים לאפשר דרך גישה לגג, הרי שבהקשר זה נאמר בפסק הדין בהליך הקודם כך-

" מאידך, אין ספק, וגם הנתבעים עצמם מודים בכך, כי על הנתבעת להכשיר עלייה לגג מתוך חדר המדרגות באמצעות סולם, כפי שהדבר היה עובר לעבודות הבנייה שעשתה הנתבעת. ברם, גם עניין זה אינו במסגרת הסעדים שנתבקשו בתביעה זו.

על כל אלו ייאמר כי צודקים הנתבעים בטענתם כי התובעים סיכלו במו ידיהם מציאת פתרון עליה לגג. שעה שביקשה הנתבעת להשיב את המצב לקדמותו כפי שהיה מלפני שנים ולפתוח פתח מחדר המדרגות לגג, הם פנו לבית המשפט במסגרת בש"א 4571/06 וביקשו למנוע ממנה לעשות כן. משכך, ומשהוכח שמעולם לא ניתנה למי מדיירי הבית גישה חופשית לגג באמצעות גרם מדרגות, ומשהוכח שלא ניתנה הסכמת הנתבעת לעשות כן, ומשהוכח שהתובעים מנעו מציאת פתרון חלופי, אין להם להלין אלא על עצמם". (ראה סיפה לפסקה 18 ופסקה 19 לפסק הדין בהליך הקודם).

50. הנה כי כן, אף באשר ליצירת דרך גישה חלופית לגג, אמר בית המשפט את דברו וקבע כי היעדרה של דרך גישה רובצת לפתחם של התובעים אשר מנעו בעצמם את יצירתה. עם זאת נקבע, כאמור, כי אין מחלוקת בין הצדדים כי חלה החובה על הנתבעת שם (גיל) לעשות כן. בית המשפט לא הורה לעשות כן שכן לא היה סעד זה מנוי בין הסעדים המבוקשים.

51. גם בהליך דגן הנתבעים אינם חולקים על חובתם ליצור דרך גישה לגג באמצעות סולם, ואף מוכנים לעשות כן (ראו סעיף 4 יד לסיכומי הנתבעים), אולם לטענתם מי שמסכל את הוצאת הדברים מן הכוח אל הפועל אלו הם התובעים, המתעקשים על שימוש במדרגות בלבד.

52. אוסיף ואומר, כי ממילא נכון היה לדחות את דרישת התובעים להורות לנתבעים לאפשר גישה לגג באמצעות מדרגות, שכן לא הוכח בפני כי הבנייה שביצעו הנתבעים היא זו שמנעה את הגישה לשם. גם מהראיות שנשמעו בפני עולה כי עוד טרם ביצעו עבודות השיפוצים על ידם, לא הייתה גישה לגג, אלא דרך המדרגות בדירתם. בנוסף, מקובלת עלי גם עמדת הנתבעים כי לא הייתה כל גישה "חופשית" למדרגות דירתם המובילות לגג ישירות מחדר המדרגות (הנתבעים טענו כי הייתה דלת אחת שהפרידה בין חדר המדרגות למבואת הכניסה לדירה- דרכה ניתן היה להגיע למדרגות העלייה לגג, ודלת נוספת המפרידה בין מבואת הכניסה לדירת הנתבעים עצמה). לא מצאתי כל מקור חוקי המחייב את הנתבעים לאפשר את המעבר לגג, כעניין שבשגרה, דרך דירתם הפרטית.

53. כך למשל, מהימנה עלי עדותה של הנתבעת אשר העידה בהקשר זה כך :

ש. אני אומר לך שלפני שקניתם, הייתה כניסה לדירה של משפחת גיל (מפנה לעמוד לפני האחרון לנספחי התצהיר של שמחוביץ) הייתה שם דלת, מהדלת הוביל מסדרון עד למדרגות שעולים איתם לגג, אחרי המעלה למדרגות הייתה עוד דלת שהפרידה בין הדירה מהחלק של המסדרון עם עליית הגג וככה נשמרה הפרטיות של משפחת גיל, את זוכרת שככה קניתם.

ת. זה שקר מוחלט, זה לא נכון בכלל. הדלת שנכנסים לדירה שלי הייתה אותה דלת שקיימת היום. כשנכנסים לדירה והולכים ימינה את כל הדרך עד לחדר של הבת שלי, זה היה שטח פתוח. היה מסדרון קטן שהוביל למדרגות אבל לא הייתה דלת.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

54. עדות הנתבעת נתמכת גם בראיות נוספות- כך למשל, הקבלן, מר שמעון רחמים, העיד כי: " **פתח הכניסה לדירה הושאר כמו שהוא ואפילו התחברנו למשקוף הקיים**" (ראה פרוטוקול מיום 19.11.13, עמ' 11 שורה 32). בנוסף, התובעים, אשר נטל ההוכחה מוטל על כתפיהם, לא הביאו לעדות ולו אחד מדיירי הבית המשותף על מנת שיעיד כי אכן דלת הכניסה לדירת הנתבעים, טרם שאלו החלו בשיפוצים, הייתה במקום שבו הם טוענים שהייתה, וכי הייתה כניסה ישירה למדרגות דרכה באופן הנטען על ידם. חזקה שאם אכן כך היה, היה בידי הנתבעים להעיד לפחות בעל דירה אחד על מצב עובדתי זה. במצב דברים זה הרי שחלה ההלכה לפיה צד שנמנע מלהציג ראיה רלוונטית או מלהעיד עד רלוונטי, חזקה כי עדותו הייתה משמשת לרעתו (ראה: ע"א 548/78, **שרון נ' לוי**, פ"ד לה (1) 736, ע"א 635/89, **אנקונה נ' גוטמן**, תק- על 90 (3) 705 (1990), ע"א 27/91, **קבלו נ' שמעון**, פ"ד מט (1) 450 (1995), יעקב קדמי **על הראיות-הדין בראי הפסיקה** (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650).

55. אעיר עוד כי אמנם בביקורי במקום ראיתי כי קיימת סגירה של דלת במקום בו נטען כי הייתה קיימת דלת הכניסה לדירת הנתבעים בעבר, אולם לא הוכח בפני כי דלת זו "נסגרה" על ידי הנתבעים עצמם. לפיכך, השינוי היחיד שביצעו הנתבעים הוא העברת המדרגות ממקום אחד בתוך דירתם למקום אחר בתחומי אותה דירה.

56. במצב דברים זה, נוכח הסכמת הצדדים ובשים לב לכך שהסעד המבוקש הנו "**להורות לנתבעים לאפשר... גישה חופשית לגג**", על הנתבעים לאפשר גישה חופשית לגג באמצעות **סולם** מחדר המדרגות (שכן, כאמור, על הנתבעים לא חלה כל חובה לאפשר גישה זו דרך גרם המדרגות שבדירתם). אמנם, התובעים מתנגדים נחרצות להצבת סולם (ראה סעיף 59 לסיכומיהם, ראה גם האמור בפסק הדין בהליך הקודם בדבר סיכול מציאת פתרון על ידי התובעים עצמם)- אולם לא מצאתי כי חלה על הנתבעים חובה לאפשר גישה באמצעות מדרגות, ודי בהצבת סולם.

57. היות שהסולם הוא ברכוש המשותף ואין כל בעלי הדירות צד להליך שלפני, בנייתו טעונה, לכל הפחות, את הסכמת האסיפה הכללית (ראה סעיף 2 (א) לתקנון המצוי, תוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969).

צינור הביוב והצנרת הנוספת

מעשה בית דין?

58. בפסק הדין בהליך הקודם הוגדרה הצנרת הנדונה שם כך- "**צנרת האינסטלציה שהותקנה לניקוז שפכי תוספת הבנייה**". הסעד שהתבקש ביחס לאותה צנרת היה, כעולה מפסק הדין, סילוק הצנרת או לחלופין תיקונה. בהליך הקודם נטען כי צנרת זו לא הותקנה כראוי וכתוצאה מכך זרמו מי השפכים אל מחוץ לצנרת על הקירות ועל החצר של הבית המשותף (ראה סעיף 1 לפסק הדין, עמ' 2, שורות 8-10).

59. מפסק הדין עולה כי הטענה בנוגע לצנרת נזנחה בסיכומי התובעים שם ואף התיישנה, וכי מכל מקום בית המשפט נתן אמון בגרסת מר רמי (רחמים) כהן (אשר התגורר עם אמו בדירה שמתחת לדירת הנתבעים) ממנה עלה כי לא קיימת בפועל כל בעיה עם הצנרת, ומי הצנרת אינם נשפכים על קירות הבניין או החצר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

60. שלא כמו בעניין המדרגות, בכל הנוגע לצנרת אינני סבורה כי חל כלל מעשה בית דין, וזאת ממספר טעמים. ראשית, מפסק הדין בהליך הקודם לא ניתן לדלות בבירור את מיקומה של אותה הצנרת, כך שאינני יכולה לקבוע כי מדובר באותו מיקום בו עסקינן כעת, היינו על החזית הפונה לרחוב הצפירה. שנית, הראיות והעדויות שנשמעו בהליך זה לא שפכו די אור על מיקום הצנרת שנדונה בהליך הקודם, וגם לפיכך אין בידי לקבוע כי המדובר באותה הצנרת. שלישית, קביעת בית המשפט בהליך הקודם נכונה למועד הינתנה ("... כיום לא זורמים מים מצנרת זו, לא על קירות הבניין ולא אל החצר"- ראה שם בפסקה 22), ואין בה כדי לקבוע ממצאים באשר למפגעים חדשים, אשר אירעו (כך על פי הטענה) לאחר מועד מתן פסק הדין.

61. לסיכום עד כאן:

כלל מעשה בית דין חל בכל הנוגע לטענות התובעים באשר לבנייה חדשה שביצעו הנתבעים ואשר מנעה כביכול את הגישה לגג (מכל מקום, אף אם לא חל כלל זה, מהראיות שנשמעו בפני הוכח כי אין בבניה שביצעו הנתבעים בכדי לשנות את דרכי הגישה לגג, וכי עוד טרם רכישתם את הדירה לא הייתה אפשרות למעבר לגג המשותף שלא דרך דירתם). לא כך הדבר באשר לטענות הנוגעות לצנרת, לגביהן לא חל כלל מעשה בית דין. לפיכך, יש להמשיך ולבחון את טענת התובעים בכל הנוגע לצנרת אותה התקינו הנתבעים, לטענתם, בחזית הבית המשותף.

המסגרת המשפטית

62. סעיף 2(א) לתקנון המצוי קובע:

" בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה "פגיעה ברכוש המשותף"- לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

63. הנה כי כן, כאשר מדובר בשינוי או תיקון "הפוגע ברכוש משותף", לרבות בחזותו החיצונית, יש לקבל לשם כך את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

64. לעומת זאת, כל עוד אין המדובר בשינוי או תיקון "הפוגע ברכוש המשותף" כאמור לעיל, הרי שניתן לעשות ברכוש המשותף "שימוש סביר", וזאת מבלי שיהא צורך לקבל לשם כך את הסכמת בעלי הדירות.

65. שימוש סביר ברכוש משותף, כזה אשר אינו מצריך את הסכמת בעלי הדירות, הוגדר בפסיקה כשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואשר איננו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה: ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', כח (1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברח' שחראי 14-18, פ"ד לה (4) 277).

66. בפסיקה הוכר שימוש סביר לא רק ככזה אשר מהותו בארעיות וזמניות השימוש (כגון ישיבה בגינה או חניה בלתי קבועה של רכב בתחומי הרכוש המשותף), אלא במקרים מסוימים אף שימוש הנוטה להיות קבוע. כך למשל, הכירה הפסיקה, בתנאים מסוימים, בהצבת מנועי מזגנים על גג הבית המשותף או



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בתלייתם על גבי קירותיו החיצוניים כ"שימוש סביר", על אף שינוי מראהו החיצוני של הבית המשותף ויסוד "הקביעות שבו". זאת, כאשר נמצא כי הצבת המזגנים לא הגיעה כדי "פגיעה בחזותו החיצונית" של הבית המשותף.

67. בע"א (ת"א) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 13.1.98), אמר כב' השופט א. גורן דברים מהם ניתן ללמוד גם לענייננו:

"דעתי היא, שהנחת שני מזגנים על גג הבית המשותף אינה מהווה פגיעה ברכוש המשותף. הלכות בית המשפט העליון בהן נאמר, כי גם פגיעות קטנות מהוות פגיעה ברכוש המשותף לא חובקות גם את המקרה דנן, שכן במקרה זה אין פגיעה ברכוש המשותף, ואין כל פגיעה בשלמות המבנה או בתקינותו. אם נוצרת איזושהי אי שלמות ארכיטקטונית מינורית היא אינה מהווה "פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה" (כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי), אלא לכל היותר שינוי זניח בגג בית שחזותו החיצונית ממילא אינה אחידה לחלוטין, לכל הפחות, מפאת המצאותם של מזגנים של בעלי דירות שונות בבית המשותף על קיר הבית. שינוי זה הוא לכל היותר פגיעה אפסית שכל בר דעת היה רואה בה דבר של מה בכך, כלשונו של השופט גולדברג בפס"ד אליאס נ' שיפר הנ"ל. המערכת אף לא טענה כלל, כי המזגנים על גג הבית פוגעים באיזושהו אידיאל אסתטי ארכיטקטוני לו דיירי הבית שואפים מאז הקמתו ופועלים להגשמתו, אלא סתם כי אינם נוחים למראה עיניה, בלא כל הנמקה ממשית. יש לציין אף, כי המזגנים על גג הבית אינם פוגעים בערך הדירות בבית ולא מסכנים את קיומו" (ההדגשות במקור- י.ע.ש).

ראה גם: ע"א (י-ם) 2560/01, נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 19 נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.4.02), שם נאמר עוד כי:

"הערכאה הקודמת ציינה בהכרעתה, כי בשנים האחרונות מסתמנת בפסיקת המפקחים על רישום המקרקעין מגמה לראות, בנסיבות מסוימות, התקנת מזגן כשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בכפוף לתנאי הזמן והמקום. דעתנו היא, שיש לעודד מגמת פסיקה זו לאור תנאי האקלים בארץ. כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל"

68. כאן המקום להזכיר גם את פסק הדין שצירפו הנתבעים לסיכומיהם - עפ"א (מחוזי מרכז) 22823-03-12, **יצחק נחשון נ' עיריית ראשון לציון** (פורסם ב"פדאור", ניתן ביום 15.1.12). שם, שלא כבמקרה דנן, נדון הליך פלילי בגין הצבת צינור ביוב על גבי הקירות החיצוניים של בית משותף, הליך שהסתיים בזיכוי נוכח אכיפה בררנית וקבלת טענת "זוטי דברים". יחד עם זאת, מפסק הדין ניתן ללמוד כי בית המשפט המחוזי



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בחן עד כמה פוגעת הצבת הצינור בחזית הבית המשותף והאם הוצבו צינורות דומים נוספים על ידי בעלי הדירות. ללמדך, כי כאשר מדובר בחזית של בניין ותיק, עליו כבר קיימים צינורות דומים, ספק אם טענת הפגיעה בחזית הבית המשותף מבוססת דיה.

69. הנה כי כן, מהפסיקה שאוזכרה לעיל ניתן ללמוד כי יש לבחון האם הפגיעה הנטענת בחזית הבית המשותף היא אכן כזו המצריכה את הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית, או שמא מדובר בשימוש שניתן לראותו כ"שימוש סביר ברכוש משותף", בנסיבות העניין. יש לתת את הדעת לכך שגם שימוש קבוע בקירות החיצוניים של הבית המשותף יכול להיות שימוש סביר, וזאת אם נמצא כי איננו גורם לפגיעה ב"חזותו החיצונית התקינה והאחידה" של הבית המשותף (כמשמעות מונח זה בסעיף 2א לתקנון המצוי), כי אם לפגיעה מינורית, אם בכלל. כל זאת יש לבחון בהתאם לתנאי המקום והזמן.

70. נפנה, אם כן, לבחינת הנסיבות המקרה הנדון.

מן הכלל אל הפרט

71. לא מצאתי בסיס לטענת התובעים בכל הנוגע לצינור הביוב (ארבעה צול) שהתקינו הנתבעים על חזית הבית המשותף (להלן: "הצנרת"). מדובר בחזית המשותפת בצינורות לרוב ומנועי מזגן גדולים. כך כעת וכך היה גם טרם שהתקינו הנתבעים את הצנרת. על רקע זה, לא מצאתי כי התקנת הצנרת מהווה פגיעה בחזית הבית המשותף, המצדיקה להורות על פירוקה והשבת המצב לקדמותו.

72. אנמק מסקנתי זו להלן.

73. התובע אישר בעדותו (ראה בפרוטוקול עמ' 5 שורות 39-37), כי לפני שהוחלפה הצנרת הישנה לצנרת הנוכחית (הכוללת צינור 4 צול), המצב היה כזה שעל אותה חזית של הבית המשותף היו שמונה או תשעה צינורות (ראה בפרוטוקול הדיון, עמ' 5 שורה 6, שורות 31-30). התובע גם אישר שהמצב היום הוא כמו שמופיע בתמונות 4/1 ו-5/2 (צורפו כנספחים לכתב הגנה לכתב תביעה מתוקן). בתמונות אלו נראית חזית הבית המשותף "מעוטרת" במזגנים גדולים, צלחות לוויין וצינורות למיניהם. כן הוא אישר שעדיין קיימים צינורות נוספים באותה חזית, צינורות מי קולחין לטענתו (עמ' 3 שורות 24-22). לאחר שעומת עם תמונה (1/ת) אישר גם התובע כי כיום קיימים בסמוך לצינור נושא המחלוקת עוד תשעה צינורות (עמ' 3 שורה 46).

74. ממוצג 2 נגלית חזית הבניין הפונה לכיוון רחוב הצפירה. נראים בבירור מספר צינורות לכל אורך החזית וכמה לרוחבה. שני מנועי מזגן גדולים מוצבים מעל הכניסה לבית. על חזית זו מוצבת הצנרת.

75. גם בביקורי במקום ראיתי כי מדובר בחזית שאיננה מטופחת או שמורה כלל, מותקנים עליה צינורות שונים, מזגנים וכדומה. הצנרת וצינור הנוסף שהתקינו הנתבעים, בנסיבות אלו, פוגעת באופן מינורי, אם בכלל, בחזית הקיימת. לו היה מדובר בחזית החפה מכל צנרת או מתקן חיצוני בולט, ייתכן מאוד כי



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

מסקנתי הייתה שונה. או אז אפשר שהתקנת צינור של 4 צול בחזית הייתה בולטת במיוחד ופוגעת בה פגיעה של ממש. אולם עת עסקינן בבית משותף שממילא חזיתו משופעת צינורות ומתקנים כאמור, אין בהוספתה של צנרת זו אלא עניין של מה בכך, ובנסיבות אלו מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

76. בנוסף לכך, קיימת משמעות לעובדה כי התובע, אשר שימש כיו"ר הנציגות בזמן מתן עדותו בפני (ראה פרוטוקול 19.11.13, עמ' 2 שורה 17), הודה כי הוא כלל אינו זוכר אם נושא הצנרת עלה אי פעם בישיבות האסיפה הכללית. ניתן היה לצפות כי יו"ר ועד, אשר נושא חזות הבית המשותף כה מפריע לו, כטענתו בהליך זה, היה יוזם דיון בנושא הסרת הצנרת וזוכר זאת היטב. העובדה שהתובע טען כי אינו זוכר כלל אם נושא זה עלה בישיבות האסיפה הכללית, אומרת דרשני ביחס למניעיו האמיתיים בהגשת תביעה זו, וספק אם יש בהם נגיעה כלשהי לסעד המבוקש באשר לצנרת (ובכלל).

77. לא למותר לציין כי מנספח C לתצהיר התובע (פרוטוקול ישיבת ועד מיום 25.1.12), עלה כי באסיפת הדיירים ככל הנראה דווקא עלה נושא הצנרת, אולם החלטת אסיפת הדיירים התייחסה להסתרת הצינור, היינו כיסוי "בצורה אסתטית ודקורטיבית", וכלל לא להסרתה של הצנרת לצמיתות. ספק אם נושא הסרתה עמד על הפרק, ואף אם כן, כאמור, החלטת האסיפה הכללית הורתה אך על כיסוי והסתרתו.

78. הטענות לסתימה בשל ועקב הצנרת לא גובו בראיות לביסוסן, נטענו בעלמא, ואף לא הוגשה חוות דעת מוסמכת של איש מקצוע בעניין. לפיכך, לא הורם הנטל ולא הוכח כי צנרת זו היא שגורמת לסתימות, ככל שקיימות בכלל סתימות כנטען.

79. מהטעמים המפורטים לעיל, לא מצאתי כי יש בהתקנת הצנרת פגיעה בחזית הבית המשותף, ואם קיימת כזו, הרי שבנסיבות העניין היא מזערית, ועולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף.

80. במצב דברים זה אני דוחה את הסעדים המבוקשים בכל הנוגע לצנרת (סעיף 19 לכתב התביעה המתוקן). מובן, כי אין בכך בכדי לקבוע דבר באשר לאופן הסתרת הצינור ושיפור מראה חזית הבניין, נושא שיש לקבל לגביו החלטה במסגרת האסיפה הכללית.

שימוש ייחודי בגג הבית המשותף

81. מביקורי במקום, כמו גם מביקורו של קודמי, עמיתי המפקח אורן סילברמן (ראה דו"ח ביקור במקום מיום 10.1.12), עלה כי בחלק מגג הבית המשותף (מדובר בחלק מהגג אשר לא הוצמד לדירת הנתבעים לאחר הרחבת דירתם), מוצבים פריטי ריהוט שונים של הנתבעים. כך למשל, מונחים במקום שולחן פינג-פונג, ערסל מתנדנד, שולחן וכיסא ופינת ישיבה, עציצים ושמשייה (להלן: "הריהוט"). הנתבעים אינם חולקים על כך שמדובר ברכוש משותף, אשר לכל בעלי הדירות הזכות לעשות בו שימוש סביר (ראה: פרוטוקול מיום 19.11.13, עמ' 15 שורות 16-17, סעיפים 9-10 לסיכומי התובעים).

82. בביקורי במקום לא התרשמתי כי יש בריהוט המוצב בחלק מהגג המשותף משום שימוש ייחודי ברכוש משותף (יוער כי מדובר בחלק קטן מהגג, כאשר בחלק אחר מוצבים מתקנים ודודים של יתר בעלי הדירות). מדובר בפרטי ריהוט שיתר בעלי הדירות יכולים לעשות בו גם הם שימוש, ואף הנתבעים אינם חולקים על



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

זכותם זו. כך, גם הריצוף הקיים איננו נחזה כריצוף חדש ומכל מקום, אין בו בכדי להוות שימוש ייחודי, שכן גם יתר בעלי דהירות יכולים לעשות בו שימוש.

83. מעבר לאמור לעיל יש להעיר כי ספק רב אם אכן לנתבעים יש עניין אמיתי כלשהו בשימוש בגג המשותף. התובע 1 כלל לא גר בבית המשותף (בבעלותו 1/5 חלקים מהמסעדה בלבד), והעיד על עלייתו לגג רק בתקופת ילדותו (ראה: ראה עמ' 6 לפרוטוקול, שורה 40). התובעת העידה על עצמה כי בשל מצבה הבריאותי היא איננה מסוגלת כלל לעלות לגג באמצעות סולם. מעבר לכך, גם ביחס אליה נראה כי אין לה כל עניין ממשי בשימוש בגג (במיוחד שעה שדירתה סמוכה לגינה רחבת ידיים). כפי שנקבע הן בפסק הדין של כב' השופט שטראוס ז"ל והן בהליך הקודם, בפסק דינו של כב' השופט מינץ, גם אני התרשמתי כי מטרות התובעים שונות מאלו עליהן הצהירו בפועל. התרשמתי כי אין להם כל אינטרס או עניין של ממש בשימוש בגג המשותף.

84. לפיכך, הנתבעים יוכלו להותיר את חפצי הריהוט והריצוף בגג המשותף, ובלבד שיאפשרו את השימוש בהם לכלל בעלי הדירות. עם זאת, ברי כי ככל שתתקבל באסיפה הכללית החלטה המורה על הסרת הריהוט, חלקו, או על שימושים אחרים שיש לעשות בגג, על הנתבעים לעשות כדברה.

ד. סוף דבר

85. על הנתבעים לאפשר גישה חופשית אל גג הבית המשותף באמצעות התקנת סולם, וזאת באופן ובצורה שתקבע על ידי האסיפה הכללית. הדרישה להורות על גישה לגג באמצעות מדרגות - נדחית, מחמת מעשה בי-דין.

86. הסעד הנוגע לפירוק צינור הביוב והצנרת הנוספת שהותקנו על ידי הנתבעים לאורך הקיר החיצוני ולהשבת המצב לקדמותו – נדחה.

87. הבקשה לסילוק ידם של הנתבעים מגג הבית המשותף – נדחית, בכפוף למתן אפשרות לאסיפה הכללית לקבל החלטה בדבר הסרת הריהוט שהציבו הנתבעים בגג המשותף, או על כל שימוש אחר בגג (ויובהר כי אין מדובר בחדר הנוסף שנבנה על הגג אלא בחלקי הגג הנוותרים).

88. התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים ובשכר טרחת עורך דינם בסכום כולל של 9,000 ₪. בפסיקת סכום זה התחשבתי גם בהוצאות הצדדים בהליך 104/12 (זאת בהתאם לאמור בפסק הדין באותו הליך).

89. למען הסר ספק, אין באמור בפסק דין זה בכדי לאשר בנייה או התקנה כלשהי הטעונה רישיון לפי דיני התכנון והבנייה, בהיעדרו.

ניתן היום, יח' סיון תשע"ד, 16 יוני 2014, בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין